

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

La Corte così composta:

Dott. Diego Pinto	Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin	Consigliere
Dott.ssa Fiorella Gozzer	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero **6668/2017** posta in deliberazione all'udienza del **17.11.2022** e vertente

TRA

Parte_1

Parte_2

Parte_3

Parte_4

[...]

e

Parte_5

(Avv. Claudia Ferrari)

APPELLANTI

E

Controparte_1

,

CP_2

,

Parte_6

e

CP_3

(Avv. Marcello D'Elia)

APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI

E

CP_4

CP_5

APPELLATI CONTUMACI

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. **4967/17** emessa dal Tribunale di Roma

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Tribunale di Roma, con sentenza numero 4967/2017, ha rigettato le domande, proposte dagli attori *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3*

Parte_4 e Parte_5 nei confronti di CP_1 , CP_2 , Parte_6 [...] e CP_6 , di condanna al rilascio dell'immobile sito in Roma, via del Casale Ferranti 56 e al pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile, nonché, nei confronti di Pt_6 e CP_2 e di CP_5 e CP_4 tutti nipoti unitamente agli attori chiamati all'eredità di Controparte_7 seguito della rinuncia dei figli, di scioglimento della comunione sul predetto immobile e sugli arredi, disponendo la divisione o la vendita se indivisibile; ha compensato le spese di lite; ha posto le spese di ctu a carico di ciascuna parte costituita.

Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e Parte_5 hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno chiesto, in riforma *“accertare e dichiarare il diritto alla divisione..e per l’effetto disporre ...la cessazione della comunione instauratasi..sull’immobile sito in Roma via Casale Ferranti 56..ordinare ai convenuti Controparte_1 ed ai di lui familiari: [...] CP_3 CP_2 e Parte_6 e per essi anche a tutti gli eventuali soggetti da questi interposti, il rilascio dell’immobile sito in Roma, Via del Casale Ferranti 56, - condannare il Signor Controparte_1 e gli altri occupanti tutti, per quanto di loro spettanza, al pagamento in favore degli attori, in proporzione alle singole quote di proprietà, della somma complessiva di € 189.024,00, così come quantificata nell’espletata CTU sulla base dell’accertato valore locativo dell’immobile dal 17/9/2008 sino al Dicembre 2015, prevedendo l’aumento della predetta somma, sino al dì del rilascio, dell’importo del canone locativo indicato nel listino ufficiale della Org_1 di Roma - o alla maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia - a titolo di indennità per l’occupazione ed in via subordinata a titolo di indebito arricchimento, per l’illegittima occupazione dell’immobile de quo; - disporre la divisione -disporre la divisione mediante la vendita del cespite indivisibile, determinando la quota pecuniaria di spettanza dei dividendi, anche assegnando la delega delle operazioni di vendita ad un Notaio, con ogni provvedimento*

conseguenziale..... In ogni caso con addebito delle spese del doppio grado di giudizio...”.

Controparte_1 , *CP_2* , *Parte_6* e *CP_3* costituitisi hanno domandato “ *rigettare l’appello principale perché infondato in fatto ed in diritto, siccome motivato, provato e dedotto, e, in riforma della medesima sentenza, accogliere le istanze e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e di risposta ed alla comparsa conclusionale di primo grado dei Sigg.ri* *Controparte_1* , *CP_2* [...] , *Parte_6* e *CP_3* , che devono intendersi qui integralmente per riprodotte e trascritte e, per l’effetto, dichiarare l’acquisto per usucapione ordinaria della proprietà dell’immobile sito in Roma, via Casale Ferranti, 56, con ordine alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari dell’annotazione della sentenza a pronunciarsi; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.

CP_4 e *CP_5* hanno optato per la contumacia.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in epigrafe.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia *per relationem* all’impugnata sentenza.

Orbene, l’odierno appellante ha censurato la sentenza assumendo che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto applicabile allo scioglimento della comunione ereditaria il disposto di cui agli artt. 46 D.P.R. 380 del 2001 e 40 della legge n. 47 del 1985, in quanto tale normativa andava esclusa con riguardo allo scioglimento della comunione ereditaria essendo questa ricompresa tra gli atti *mortis causa*.

La censura va disattesa.

Innanzitutto, il Tribunale a fondamento della statuizione ha evidenziato le risultanze del ctu (cfr. integrazione ctu), ovvero che il manufatto costruito era completamente abusivo e che non vi era corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile rispetto agli atti rinvenuti ed inoltre che “L’edificio non è concessionato,

e per esso al momento non vi sono autorizzazioni o concessioni amministrative e per esso non vi è nessuna agibilità. E' stata presentata domanda di condono edilizio per il solo piano terra mentre risulta del tutto abusivo il piano interrato" . Ha, altresì, ritenuto che in mancanza di alcuna indicazione o allegazione circa l'epoca di realizzazione dell'edificio questo doveva presumersi come realizzato nel periodo successivo all'1.9.1967.

Nulla sul punto è stato censurato.

La riconducibilità della divisione ereditaria alle norme individuate dal primo giudice deve ritenersi corretta.

Ciò alla stregua dell'orientamento della Corte di Cassazione che a sezioni unite (sentenza n. 25021/2019) ha affermato il seguente principio

“ Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.”.

Decisione questa di cui si ritiene opportuno riportare una parte di motivazione perché pertinente proprio alla doglianza svolta

“ deve concludersi che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 è applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione.... La prima questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite va dunque risolta con l'enunciazione - ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - del seguente principio di diritto: «Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 10settembre 1967». Dal principio di diritto appena enunciato scaturisce l'infondatezza della censura in esame, giacché l'applicabilità dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 alla fattispecie per cui è causa (per essere state

le parti abusive dell'edificio in comunione edificate - secondo l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale - prima della entrata in vigore della detta legge) non comporta affatto l'esclusione della comminatoria della nullità per gli atti di scioglimento della comunione. Una volta risolta la prima questione di diritto nel senso che lo scioglimento della comunione deve ritenersi ricompreso tra gli atti tra vivi per i quali l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 commina la sanzione della nullità, è necessario passare all'esame della seconda questione sottoposta col primo motivo di ricorso. 3. - La questione di diritto ora da risolvere è la seguente: se nel novero degli atti tra vivi, per i quali l'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (come sopra interpretato) commina la sanzione della nullità, possa includersi solo l'atto di scioglimento della comunione ordinaria, dovendo ritenersi l'atto di divisione della comunione ereditaria un negozio assimilabile agli atti mortis causa, ovvero debba includersi anche l'atto di scioglimento della comunione ereditaria, da qualificarsi invece come negozio inter vivos. Seppure, nella presente causa, in relazione all'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, rilevi solo l'applicazione dell'art. 40 cit., la questione ha valenza più ampia, investendo, nei medesimi termini, anche l'interpretazione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Essa, pertanto, può essere trattata in termini generali, in rapporto ad entrambe le norme..... Essa costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la legge n. 47 del 1985 e il d.P.R. n. 380 del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbiano ad oggetto edifici abusivi o parti di essi. 5.4. - La tesi secondo cui l'atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo non sarebbe oggetto della comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è, d'altra parte, smentita dal testo delle disposizioni appena richiamate, interpretate secondo i canoni previsti dall'art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ. - Innanzitutto, sul piano dell'interpretazione letterale della legge, secondo il «significato proprio delle parole» (art. 12, primo comma, prima parte, delle preleggi), va considerato che l'art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 (come, prima di esso, l'art. 17 della legge n. 47 del 1985) include espressamente l'atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi (o loro parti) tra gli atti inter vivos colpiti da nullità; ed analoga inclusione deve ritenersi - per quanto si è veduto supra (par. 2.) - con riferimento all'art. 40 della legge n. 47 del 1985. È dunque la legge che commina espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria. La previsione - negli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria. Si

è già rilevato, peraltro, che il fenomeno divisorio ha carattere unitario, tanto che la disciplina dettata dal codice civile per la divisione ereditaria si applica anche allo scioglimento della comunione ordinaria in quanto compatibile (art. 1116 cod. civ.) e che persino l'effetto retroattivo previsto per la divisione ereditaria vale anche per le divisioni dei beni comuni. Non vi sono, pertanto, valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985. Piuttosto, va rilevato che l'inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti da nullità ai sensi degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è coerente con la ratio legis e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscano la negoziabilità dell'immobile. La non negoziabilità con atti inter vivos dei diritti reali su edifici abusivi costituisce, infatti, un importante deterrente alla realizzazione degli abusi edilizi; e tale deterrente risulterebbe indubbiamente depotenziato ove gli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 fossero interpretati nel senso di consentire agli eredi di colui che ha realizzato la costruzione abusiva di sciogliersi dalla comunione ereditaria. Né avrebbe senso, sul piano della formazione delle quote in natura tra i condividenti, sciogliere la comunione su un edificio abusivo (non sanato), attribuendolo in titolarità esclusiva ad uno dei coeredi, quando un tale edificio deve essere comunque demolito o acquisito al patrimonio dell'ente comunale...". .

Se così, alla stregua delle fattispecie normative richiamate e interpretate dal giudice di legittimità e di quanto accertato, ossia della realizzazione del manufatto senza i necessari titoli edilizi, non può essere disposto lo scioglimento della comunione sull'immobile perché sarebbe affetto dalla sanzione di nullità, conseguentemente la domanda andava rigettata e la censura va respinta.

Con altro motivo la parte appellante ha affermato che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che stante la preclusione alla domanda di scioglimento della comunione non poteva essere accolta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.

In primo luogo vi è da dire che – per evidenti ragioni di logica preliminari - tale questione va risolta solo successivamente all'accertamento dell'intervenuto acquisto o meno per usucapione dell'immobile da parte degli appellati costituiti avendo questi

ultimi svolto appello incidentale con riguardo al rigetto (ritenuto erroneo) della domanda di acquisto in tal senso formulata.

Hanno in tal senso dedotto che abitavano nell'immobile di via Casale Ferranti n. 56 sin dal 1986, che avevano provveduto al pagamento di tutte le utenze, che avevano goduto dell'immobile in modo inconciliabile con la possibilità di fruizione altrui, poiché la CP_7 risiedeva altrove mentre gli appellanti non avevano mai avuto accesso all'abitazione a far data dalla esecuzione dei lavori di ristrutturazione, tenuto poi conto che dieci anni prima del decesso della CP_7 i figli di comune accordo avevano proceduto di fatto alla divisione dei cespiti ognuno godendo della propria porzione immobiliare.

Ora, non vi è dubbio che, così come narrato, l'immobile apparteneva alla *de cuius* e come tale dovrebbe far parte della comunione ereditaria.

Ai sensi dell'art. 1158 c.c. *“La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”*.

Per l'usucapione è, dunque, necessario il possesso continuo, pacifico, pubblico e non equivoco di tenere la cosa come propria per venti anni.

Secondo, poi, l'art. 1141 c.c. *“ Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione...”*.

Orbene, non sussiste, nella specie, la presunzione di cui all'art. 1141 c.c.. E tale circostanza deve ritenersi dirimente, anche rispetto a quelle evidenziate dal primo giudice circa la mancanza dell'elemento temporale (venti anni) e dei presupposti di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c..

La prova contraria al principio che si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto e, dunque, la prova che l'esercizio di questo sia, piuttosto, cominciato per mera detenzione, può essere data anche mediante presunzioni, purché precise e gravi.

E tali ben possono essere nella fattispecie in oggetto – stante lo strettissimo legame di parentela - il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo in ordine alla disponibilità e al godimento concesso inizialmente.

Infatti, *In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi idonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo* (Cass. 11277/2015; conf. Ordinanza n. [11315](#) del 10/05/2018 e prima ancora Cass. n. 18651/2004; Cass. n. 8194/2001 e Cass. n. 1042/98).

Cosicché, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 1144 c.c. *“gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono fornire di fondamento all'acquisto del possesso”*, manca il presupposto utile per poter usucapire in difetto di un successivo atto d'interversione.

Nessuna prova è stata data di un atto di interversione, da detenzione in possesso, ovvero di un comportamento tale da far intendere al proprietario l'avvenuto mutamento dell'esercizio del potere di fatto sul bene, non più in nome altrui, ma in nome proprio.

In primo luogo è da dirsi che la detenzione concessa con il consenso del de cuius e con l'accordo di tutti i figli (cfr. comparsa), e dunque l'utilizzo o l'uso del bene, ben poteva estendersi a tutte le utilità che potevano trarsi e dunque anche alla manutenzione dell'immobile perché diretta certamente a un migliore utilizzo dello stesso.

Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi che hanno riferito con riguardo ai lavori di ristrutturazione effettuati e inerenti piuttosto al rimborso delle spese, non sono state comunque univoche ad esternare una volontà di possedere come proprietari posto che l'asserita realizzazione di lavori a cura e spese, a prescindere dalla prova o

meno data, sarebbe stata riconducibile alla tolleranza manifestata e, come detto, al miglior uso dell'immobile.

La presunzione di tolleranza, inoltre, non può dirsi contrastata dal fatto che l'appellante ha provveduto al pagamento delle utenze perché ragionevolmente dette spese, stante altresì, il rapporto parentale sono in capo a chi ha il godimento.

La mera disponibilità dei beni non è, dunque, utile ai fini del possesso *ad usucapionem* ed è del tutto inidonea a supportare la domanda in mancanza di un successivo atto di interversione, di cui è mancato un riscontro probatorio (Cass. 12080/18).

Detto ciò, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione va, comunque, rigettata.

E' noto al Collegio l'orientamento secondo cui

“ L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. Civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso... (Cass. n.2423/2015) e ancora (Cass. 1738/2022) Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.”.

Sono in atti due missive, una, di *Parte_1* e *Parte_2*, in data 12.6.2008 diretta a *CP_2* con la quale veniva richiesto di lasciare libera l'abitazione di via Del Casale Ferranti 56 entro e non oltre sei mesi "...avendo necessità di procedure alla divisione", l'altra, inviata da *Parte_3* a *Controparte_1*, datata 10.9.2008, del seguente tenore "Ti Rendiamo partecipi che, se dovessimo accettare l'eredità, sarà nostra intenzione vendere le nostre quote a prezzo di mercato...Ti ricordo..che per il periodo 2006/2008, ci deve essere riconosciuto un affitto dell'immobile da Voi occupato inerente alle nostre quote della successione ereditaria..".

Orbene, il contenuto di dette lettere, in uno al fatto che comunque sono state inviate solo da alcuni comproprietari, nonché la domanda come formulata (cfr. citazione) non sono idonei - in ossequio al principio del giudice di legittimità - a determinare l'accoglimento della censura, sia perché non richiesto l'uso turnario, sia perché non provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.

Consegue da tutto quanto ritenuto il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.

Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, possono essere compensate anche per il presente grado di giudizio. Nessuna pronuncia va resa per i contumaci.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- nulla per i contumaci;

- dichiara la parte appellante e la parte appellata incidentale tenute ciascuna per legge al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/12.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023

Il Consigliere estensore

Fiorella Gozzer

Il Presidente

Diego Pinto